

1502676-29.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto

Magistrado: Renata Marques de Jesus

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/06/2022

... ter sido processada criminalmente por trafico, tendo cumprido pena na rua, e não conhecer as testemunhas arroladas (fls. 257/258).

Destaca-se que não há motivos para que o policial militar acusasse o réu ROBERTO, leviana e gratuitamente, lembrando que disse sequer conhecê-lo anteriormente aos fatos. Ademais, a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

2ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502676-29.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502676-29.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2297879/2021 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 21151762 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 3542/21/203 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2297879 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

ROBERTO FRANCISCO ALVES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Marques de Jesus

Vistos.

ROBERTO FRANCISCO ALVES e FABIANA INÁCIO ARAUJO, ambos qualificados, estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, porque no dia 01 de novembro de 2021, por volta de 21 horas, na Rua Rio Novo, nº 224, Jardim Alegria, cidade e Comarca de Francisco Morato, subtraíram para si um aparelho celular Samsung A-71, IMEI 354702115039995, avaliado em R\$ 1.500,00, pertencentes à vítima Iona Andreia Gomes Rocha da Silva (fls. 5/6).

A prisão em flagrante do réu Roberto foi convertida em preventiva (fls. 70/72).

A denúncia (fls. 1/3) e aditamento (fls. 4/6) foram recebidos às fls. 104, 170 e 248.

Citados (fls. 116/117 e 200/201), os réus apresentaram respostas à acusação (fls. 141/142 e 213/214).

Em instrução foram colhidos os depoimentos da vítima (fls. 252) e de duas testemunhas comuns (fls. 253/254). Ao final os réus foram interrogados (fls. 255/256 e 257/258). Mídia arquivada.

Em debates pugnou o Ministério Público pela condenação nos exatos termos da denúncia, observando os maus antecedentes e reincidência, com fixação de regime inicial fechado (fls. 249). A Defesa de FABIANA, por seu turno, requereu, em resumo, a absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal ou, então, a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 155, caput, com fixação de pena mínima, a ser cumprida em regime inicial aberto, com direito de recurso em liberdade (fls. 249/250). A Defesa de ROBERTO também pleiteou a absolvição ou o reconhecimento da prática delituenta em sua forma simples e tentada, impondo-se pena mínima, com aplicação da atenuante da confissão (fls. 251/252).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão inicial é parcialmente procedente.

A materialidade restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 7/13), boletim de ocorrência (fls. 14/18), autos de exibição e apreensão e de entrega (fls. 21) e de reconhecimento de objeto (fls. 22), além da prova oral produzida colhida sob o crivo do contraditório, corroborada pela própria confissão do réu ROBERTO.

A autoria de ROBERTO é certa.

A vítima Iona Andreia Gomes Rocha da Silva Madeira contou que trabalhava na Lapa e estava dentro do trem. Uma senhora estava sentada com uma criança. Foi a ré quem furtou. Não foi o réu. Ambos estavam no trem. Ela pegou o celular. O vagão no dia não estava tão cheio. Na delegacia queriam que o rapaz fosse incriminado. Eles desceram na estação de Perus. Seu esposo rastreou o celular. Chamaram policiais, que foram até o local e encontraram os réus, crianças e vários celulares, inclusive o seu. Não viu o momento que tiraram o celular de seu bolso. A ré estava do lado e o réu mais para frente. O delegado gritou, dizendo que a mulher não ficaria presa, mas o réu sim, pois tinha várias passagens. O marido queria "segurar" por ela. Seu aparelho celular foi recuperado sem nenhum dano. Esclareceu que estava em pé no trem, junto com sua sobrinha Larissa, ao lado de uma senhora e uma criança. A ré estava em pé também. O celular estava no bolso da frente de sua calça. Foi muito rápido. Quando percebeu que o celular não estava no bolso, sua sobrinha ligou e escutaram o telefone tocando no fundo do vagão. Não viu com quem estava o aparelho. Os réus foram para frente e depois saíram juntos do vagão (fls. 252).

Larissa Souza da Silva narrou ser sobrinha da vítima. Contou que estavam voltando do serviço e entraram no trem, na Lapa. Estavam do lado da porta. Uma senhora estava sentada com uma criança no banco preferencial. Do outro lado estava um casal. O trem não estava muito cheio. A criança passou mal e sua tia agachou para ajudar. Quando levantou percebeu que tinham levado o seu celular. Começou a ligar e o celular tocou no fundo do vagão. Foi seguindo e viu um casal. Eles saíram. Ligou para o seu tio e ele rastreou o aparelho. Ele falou que o celular estava em Perus.

Desceram naquela estação e chamaram a polícia. O policial André foi quem prestou auxílio. Não se lembrou do nome de outros policiais. Acharam o aparelho na casa de um casal, o mesmo que tinham visto no trem. Na casa também tinham várias crianças e muitos celulares. O celular da sua tia também estava lá na casa, reconhecendo o casal presente em audiência como sendo aquele que viu no trem e também na casa. Não viu quem estava com o celular da sua tia dentro do trem, pois "não pegaram para atender". Os dois saíram do trem, a porta fechou e eles ficaram rindo (fls. 253).

A testemunha André Luiz Ferreira da Silva, policial militar que participou da ocorrência, relatou que estava em patrulhamento pelo Centro de Franco da Rocha e perto da estação de trem foram abordados por duas moças correndo. Uma delas tinha tido seu celular subtraído na região de Perus. O marido começou a rastrear o celular e passaram a localização. Deslocou-se para a residência e no local seu parceiro ligou no telefone, ouvindo tocar dentro da casa. Foram atendidos pela ré e na sequência pelo marido. Ele assumiu a autoria do furto e informou a existência de outros aparelhos celulares. Foram oito aparelhos apreendidos no total. Não conhecia os acusados antes dos fatos. A ré disse que não participou de nada, mas as testemunhas informaram que viram ela dentro do trem, embora não tenham visto o ato da subtração (fls. 254).

No mesmo sentido foram as declarações extrajudiciais do também policial militar Danilo Martins Costa (fls. 10).

Na fase inquisitorial o réu Roberto confessou o crime, dizendo que trabalha como marreteiro no trem e ao retornar para casa "percebeu uma mulher facilitando com um aparelho celular, ocasião em que enfiou a mão em seu bolso e efetuou a subtração do aparelho" (fls. 12). Já em juízo disse que sua esposa não estava no local. Vinha do Brás e pegou o trem que ia para Francisco Morato. Viu a senhora e uma moça entrarem. Viu o celular no bolso. Quando ela entrou puxou o aparelho. Passou para o outro vagão e foi para o final, onde ficou até Franco da Rocha. Desceu em Franco da Rocha, não desligou o aparelho e foi para sua casa. Sua esposa estava trabalhando. Os policiais chegaram e o chamaram. O aparelho estava sendo rastreado. Confessou o furto em Pirituba, no momento que a vítima ia embarcar. A vítima não o viu, somente na delegacia. Sua esposa não estava no momento. Pegou o aparelho celular sozinho. Declarou ter 48 anos de idade, ter duas filhas menores de idade, trabalhava como ambulante no Brás, com renda aproximada de R\$ 100,00 por dia, já foi preso por furto e roubo e estava em condicional e não conhecer as testemunhas arroladas (fls. 255/256).

A ré Fabiana negou os fatos nas oportunidades em que ouvida (fls. 13 e 257/258). Em juízo afirmou que estava trabalhando em Franco da Rocha, das 8h às 17h. Mora em Francisco Morato. Utiliza-se de ônibus para se deslocar da casa para o trabalho. Chegou em casa e seu marido já estava com os celulares. Ele disse que "fez rolo na Sé". Seu marido faz bico de pedreiro e na data disse que saiu para ver um trabalho em São Paulo. Chegou em casa e foi "esquentar a janta". Uns trinta minutos depois chegaram os policiais. Seus filhos também estavam em casa. Seu marido estava no quarto. Saiu e foi para fora conversar com os policiais. Não ouviu o que ele disse. Declarou ter 43 anos de idade, ter dois filhos menores de idade, trabalhar como doméstica, com renda R\$ 1200,00, morar em casa própria, já ter sido processada criminalmente por tráfico, tendo cumprido pena na rua, e não conhecer as testemunhas arroladas (fls. 257/258).

Destaca-se que não há motivos para que o policial militar acusasse o réu ROBERTO, leviana e gratuitamente, lembrando que disse sequer conhecê-lo anteriormente aos fatos. Ademais, a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos.

Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para, depois,

quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade. Assim entende a jurisprudência:

"O depoimento de policial obedece os mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional "1;

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição"2;

"Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e demonstrada em cada caso"3.

Como se vê, a partir do contexto probatório extrai-se que a vítima e as testemunhas prestaram depoimentos coesos e convergentes, reafirmando as declarações prestadas na fase policial, tornando seguro um decreto condenatório em relação ao réu Roberto.

E não demonstrou a Defesa eventual motivo que os agentes de segurança teriam para mentir em juízo, deixando, assim de se desincumbir de seu ônus (artigo 156, do Código de Processo Penal), destacando que eventuais e pequenas contradições entre os depoimentos, sequer existentes na hipótese, não são capazes de infirmar a lisura do trabalho policial.

Os depoimentos colhidos em juízo, repita-se, foram seguros, firmes e coerentes com os demais elementos de prova, corroborados pela própria confissão do réu, apresentada em juízo (fls. 255/256) e em solo policial (fls. 12), tornando, repita-se, certo o decreto condenatório.

Assim, pelo que se pode aferir da prova produzida, o acusado ROBERTO praticou o crime de furto, subtraindo o aparelho celular da vítima.

In casu, impossível a aplicação do princípio da insignificância. Em determinadas hipóteses tem-se por aplicável tal princípio, que, como assentado pelo Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 84.412-0/SP, depende da mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Analisando os vetores apontados, inviável a aplicação, no caso concreto, do princípio da insignificância, com o afastamento da ilicitude da conduta, sob pena de esvaziamento do próprio tipo penal do furto. Não estão reunidas no caso todas as circunstâncias expostas, sequer havendo que se falar em mínima reprovabilidade do comportamento, a merecer destaque a reincidência.

Por fim, o delito foi consumado, porque o réu apoderou-se do bem da vítima, só tendo sido preso após localização, quando já estava em sua residência, e pronta e efetiva abordagem da polícia militar.

O réu, pois, teve a posse do bem subtraído, ainda que por pouco tempo:

"O crime de roubo, assim como o de furto, se consuma quando o agente obtém a posse,

ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessário que esta se dê de forma mansa e pacífica. Doutrina. Jurisprudência" (STJ, HC 199613/SP, j. 26/03/2013);

"Tendo o agente subtraído a res e a retirado do local do furto, vindo a ser preso em flagrante algumas quadras depois, tal conduta revela a consumação do delito, não sendo possível a desclassificação para o crime na sua forma tentada". (TJMS, 2ª Turma, Apelação Criminal nº 2006 020.141-1/0000-00, Rel. Des. João Carlos Brandes Garcia, j. 31/01/2007);

"Furto qualificado. Concurso de agentes e escalada. Subtração de telhas de zinco de um barracão, no qual os agentes ingressaram através da cobertura. Réus surpreendidos nas proximidades do local do crime, na posse da 'res' e de uma ferramenta turquesa. Prova hábil. Condenação de rigor. Penas bem fixadas. Apelo de CLÁUDIO improvido. Apelo de EZEQUIEL provido em parte, estabelecido o regime aberto." (TJSP, 5ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.08.119180-6, Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 01/10/09);

"Apelação - Furto - Materialidade e autoria bem delineadas - Prova dos autos dando conta de que o réu pulou o muro, quebrou o vidro, invadiu a residência da vítima e, logo após se evadiu, levando consigo vários objetos - Confissão do réu corroborada pelas declarações da vítima, pelos depoimentos dos policiais e da testemunha civil ouvida - Qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo demonstradas pela prova oral e pelo exame pericial do local dos fatos - Absolvição ou afastamento das qualificadoras - Impossibilidade - Pleito visando o reconhecimento da tentativa - Impossibilidade - Réu preso em flagrante, em poder dos bens furtados, após diligências efetuadas pelos policiais - Réu que teve a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, ainda que por breve espaço de tempo - Pena fixada no mínimo legal - Confissão espontânea corretamente compensada com a agravante da reincidência - Regime prisional inicial fechado, haja vista se tratar de réu reincidente que cometeu furto consumado duplamente qualificado, em plena luz do dia, revelando audácia e destemor - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis - Impossibilidade - Sentença mantida - Apelo improvido." (TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.08.187416-4, Rel. Des. Borges Pereira, j. 29/09/09).

Aplicável à espécie, ainda que por analogia, o disposto na Súmula 582, do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida á perseguição imediata ao agente da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para dar credibilidade à acusação, sendo de rigor a procedência da pretensão punitiva para a condenação do acusado ROBERTO como incurso nas sanções do artigo 155, 'caput', do Código Penal.

No que tange à corré FABIANA, todavia, a prova colhida sob o crivo do contraditório deixa dúvidas acerca da autoria que, nesse diapasão, é incerta, culminando, assim, com sua absolvição.

Não se ignora que a acusada estava no local da prática delitiva (vagão de trem), todavia, não restou comprovado nos autos que ela, de qualquer forma, concorreu para a prática do crime perpetrado.

A ré, tanto em solo policial quanto em juízo, negou as acusações. A vítima e a testemunha Larissa, muito embora tenham reconhecido a ré no local dos fatos, não trouxeram elementos a permitir a conclusão de sua participação na empreitada criminosa.

E do depoimento do policial que atendeu a ocorrência igualmente não permite aferir

que, de qualquer forma, FABIANA concorreu com o delito.

O quadro probatório existente, pois, não permite a condenação, por ser frágil.

É de concluir, pois, que não dispõe o conjunto probatório formado de força suficiente para fundamentar édito condenatório. Como se vê, finalizada a instrução, não foram produzidos elementos suficientes à formação de um juízo de convicção quanto à responsabilidade de FABIANA no evento delituoso.

Ainda que comprovada a materialidade delitiva e a prática do furto pelo seu marido ROBERTO, repita-se, há severa dúvida na hipótese quanto à autoria de FABIANA e, além disso, inexistem elementos a indicar que a ré eventualmente tenha anuído com a conduta de terceiro, sendo forçoso reconhecer a ausência de provas.

Segundo Heleno Cláudio Fragoso: "Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade" (Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, p. 506). Ademais, "o Direito Penal não opera em conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal proferir condenação" (Apelação 170.407, TACRIM-SP).

Como sabido, a prova no processo penal deve ser suficientemente firme no sentido da ocorrência dos fatos e da autoria e, em assim não sendo, há de ser aplicada a máxima "in dubio pro reo", garantindo-se o respeito aos direitos individuais e ao Estado Democrático de Direito.

Para a condenação é indispensável a existência de prova segura, firme e valiosa e, existindo sombra de dúvida, como neste caso, a absolvição se impõe, como medida de inteira justiça:

"EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ESTUPRO. PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO. Sendo frágil a demonstração da autoria e da materialidade do delito, deve-se aplicar ao caso o princípio do in dubio pro reo para manter-se a absolvição do acusado." (TJMS, 2º Turma Criminal, ApCrim nº 2010.021970-3, Des. Romero Osme Dias Lopes, DJ 13/09/2010).

"Prova - Insuficiência - Meros indícios que não bastam para a condenação criminal - Autoria que deve ser concludente e estreme de dúvida - Absolvição decretada. Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes a absolvição do réu deve prevalecer" (TJMT, 2ª C., Rec. em AP, j. 12/5/93, Rel. Inácio Dias Lessa, RT 708/339).

Os indícios de prova suficientes a ensejar a deflagração da ação penal em face de FABIANA não se converteram em provas sólidas necessárias ao decreto condenatório.

Assim, diante do que resultou apurado, forçoso concluir que a prova colhida não se mostra suficiente para lastrear um decreto condenatório em face da corré, pairando dúvida razoável sobre a participação no crime em questão, o que impõe a aplicação serena do princípio de que a dúvida a beneficia.

Desta forma, de rigor a parcial procedência do feito para condenar ROBERTO, a quem restou indubitável a autoria, e absolver FABIANA, pelos frágeis elementos colhidos à embasar o decreto condenatório.

Verificadas materialidade e autoria, passo a dosar a pena do réu ROBERTO.

Na primeira fase de aplicação, sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal observo que o réu possui extensa folha de antecedentes (fls. 41/48, 60/64 e 227/245), cometeu o delito em cumprimento de pena, demonstrando personalidade voltada para prática de crimes, em especial contra o patrimônio, contando, ainda, com condenações já transitadas em julgado (v.g. autos nº 0014990-31.2009 – fls. 60; 0049034-37.2013 – fls. 61/62; 0091366-29 – fls. 62), razão pela qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Prosseguindo nos termos do artigo 68, deve ser reconhecida a agravante genérica prevista no artigo 61, II, "j" do Código Penal, de caráter objetivo, na medida em que o crime foi cometido durante o período da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), quando já estava decretada calamidade pública, com recomendação do isolamento social e outras medidas públicas (Decreto Estadual nº 64.879/20 e Decreto Legislativo nº 6/2020), o que reduz a vigilância.

A prática de crime em cenário no qual toda a população passa por privações e incertezas e em meio a diversas recomendações de recolhimento domiciliar e restrição de atividades de toda ordem é ainda mais reprovável e merece resposta penal diferenciada. A situação atualmente vivida é excepcional e, sem dúvida, do conhecimento de todos, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Ainda na segunda fase, verifico que o réu é reincidente específico (fls. 60 e 61, autos sob nº 0012038-98.2017 e 0035380-41.2017), majorando a pena em 1/3 (um terço), totalizando 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Justifica-se o aumento da agravante acima do mínimo, pois para reincidência específica, mesmo única, impõe-se tratamento diferenciado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo. II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada” (STF HC nº 101918/MS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 11/05/2010);

“A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)” (STJ HC nº 257.571/SP Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma DJe 18/02/2014).

Ainda na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena

em 1/6 (um sexto), fixando-a em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e pagamento de 11 (quatorze) dias-multa.

Na terceira, ausentes causas de aumento e/ou diminuição, mantenho a reprimenda no patamar acima estabelecido.

Sem parâmetros para elidir a presunção de hipossuficiência econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa em seu mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, § 1º, c.c. artigo 60, "caput", ambos do Código Penal. O reconhecimento da reincidência impede a concessão dos benefícios previstos no artigo 44, do Código Penal, impondo-se, pelo mesmo motivo, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena (artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Reincidente e portador de maus antecedentes, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal, fixo o regime fechado como o inicial para o cumprimento da pena segregativa de liberdade. Ainda que a pena tenha sido fixada em menos de quatro anos de reclusão, foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis e a concessão de regime mais brando tornará evidente o fracasso da reprimenda, que merece ser mais severa no caso concreto, atendendo-se, pois, ao princípio da individualização da pena:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Furto (artigo 155, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima e testemunhas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escoreita. Regime fechado mantido. Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente. Circunstâncias que autorizam a fixação de regime mais gravoso. Precedentes do STJ. Recurso não provido." (TJSP; Apelação Criminal 1500333-45.2021.8.26.0452; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piraju - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/06/2022; Data de Registro: 10/06/2022) – grifos nossos

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVAE SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU MULTIRREINCENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269/STJ. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 5. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a habitualidade delitiva do réu, que é multirreincidente, inclusive em crime da mesma natureza, com quatro condenações transitadas em julgado anteriores ao fato ora em comento, o que demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. 6. (...) 7. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Código Penal, é possível a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP. 8. Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavoravelmente valorada, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. Inteligência, a contrario sensu, da Súmula 269/STJ. 9. Writ não conhecido." (STJ, Quinta turma, HC 721299-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14/03/2022)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

A) ABSOLVER FABIANA INÁCIO DE ARAÚJO, qualificada, da imputação que lhe é feita nestes autos (artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal), com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; e

B) CONDENAR ROBERTO FRANCISCO ALVES, qualificado, como incurso nas penas do artigo 155, "caput", c.c. artigo 61, I e II, "j", ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, estes no valor unitário mínimo.

Não há elementos nos autos – principalmente os subjetivos – para a análise do previsto no art. 387, §2º, do CPP. Eventual progressão, portanto, quando cabível, deverá ser verificada em sede do Juízo das Execuções Criminais:

"Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria." (TJSP – 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 – Rel. Des.Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

O sentenciado possui diversas condenações e estava em gozo de benefício, ou seja, demonstra uma vida voltada para o crime, em especial contra o patrimônio, motivo pelo qual permanecem os requisitos da prisão preventiva. Não poderá, portanto, recorrer em liberdade. Recomende-se na prisão onde se encontra.

No mais, importa assinalar que, à luz do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, em sua atual redação, o Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. No caso concreto, todavia, não há elementos seguros nos autos a balizar o arbitramento de quantum indenizatório em favor da vítima, especialmente diante do por ela declarado em juízo.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, condenado, o réu arcará com as custas processuais:

"o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei 1.060/50. Precedentes. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase da execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação" (REsp. 400.682, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 17/11/ 2003,). No mesmo sentido: REsp. 262.961, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 17.06/2002; REsp. 263.021, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 18.03/2002 e REsp. 81.304, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 14/09/98. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso." (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0008903-30.2009.8.26.0189, Relator Des. Euvaldo Chaib).

Expeça-se certidão de honorários aos advogados nomeados nos autos (fls. 118 e 205), nos termos da tabela DPE/OAB vigente.

Após o trânsito em julgado oficie-se ao TRE, para fins do disposto no artigo 15, III da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva e arquivem-se os autos, com as anotações necessárias

Francisco Morato, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA